

1500235-39.2021.8.26.0556

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Comarca: Itápolis

Foro: Foro de Itápolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... bem de apetrechos relacionados ao tráfico (balança, anotações de contabilidade, armas de fogo e munições, etc.); c) a existência de denúncia anônima relatando que uma pessoa, com as mesmas características físicas e vestes do(a) réu(ré), estaria traficando drogas no local em que o(a) denunciado(a) estava praticando o tráfico de drogas; d) o fato de o(a) acusado(a) ter sido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itápolis

Foro de Itápolis

1ª Vara

Avenida dos Amaros, nº 800, Itapopolis - SP - cep 14900-000

1500235-39.2021.8.26.0556 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500235-39.2021.8.26.0556

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

JOÃO RICARDO OLIVEIRA DA SILVA e outro

Juiz de Direito: Dr. VINICIUS GONCALVES PORTO NASCIMENTO

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra JOÃO RICARDO OLIVEIRA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Narra a inicial acusatória que, no dia 01 de abril de 2021, por volta de 16h59, na Rua Antônio Nicolau, nº 126, Bairro Jardim Redenção, nesta cidade e comarca de Itápolis/SP, o denunciado foi surpreendido por policiais militares vendendo, 3,5 gramas da droga "Cannabis Sativa L", vulgarmente conhecida como "Maconha", acondicionada em um saco plástico tipo "ziplock", substância entorpecente que causa dependência física e psíquica (vide auto de exibição e apreensão de fl. 12/13, auto de constatação provisório de fls. 15 e laudo pericial de fl. 93/94), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.(fls. 102/104).

O réu foi devidamente notificado, apresentando resposta escrita às fls. 124/126.

Denúncia recebida em 2 de dezembro de 2021, conforme decisão de fls. 127/133.

Inexistentes os motivos legais que ensejam a absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram inquiridas 03 (três) testemunhas arroladas pela acusação, sendo, em seguida, interrogado o acusado.

Após, o representante do Ministério Público e o defensor apresentaram alegações

finais orais.
Os autos me vieram conclusos para sentença.
É o relatório.
Fundamento e decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

II.1. Das preliminares

Não foram arguidas preliminares na defesa prévia ou nas alegações finais defensivas.

II.2. Do mérito

1. Analisando as alegações das partes, bem como os elementos de prova colhidos nos autos, verifico que o Ministério Público obteve êxito na comprovação dos fatos constitutivos da pretensão acusatória.

2. Nos termos do artigo 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Ao Ministério Público incumbe o ônus de comprovar os fatos constitutivos de sua pretensão. Ou seja, deverá provar a tipicidade, a autoria, as qualificadoras, agravantes, causas de aumento de pena e o elemento subjetivo do tipo (dolo). Em suma, “Toda informação que deponha contra o réu deve ser objeto de prova pelo acusador (público ou particular)” (FREITAS, Jayme Walmer de; SILVA, Marco Antônio Marques da. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 270). Por seu turno, a defesa possui o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão acusatória. Em outros termos, deverá demonstrar as excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, causas de extinção da punibilidade, privilégios, atenuantes, causas de diminuição de pena, etc. Em suma, incumbe-lhe demonstrar a existência de circunstâncias que impliquem em atenuação da pena ou na concessão de benefícios penais.

Cumprе ressaltar que o indício, espécie de prova indireta, é, sim, suficiente para a prolação de um decreto condenatório. Conforme esclarece Guilherme de Souza Nucci, “o indício é um fato secundário, conhecido e provado, que, tendo relação com o fato principal, autorize, por raciocínio indutivo-dedutivo, a conclusão da existência de outro fato secundário ou outra circunstância. É prova indireta, embora não tenha, por causa disso, menor valia” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 632).

No caso do delito de tráfico de drogas, são indícios suficientes para a condenação do(a) agente, dentre outros: a) a confissão da prática do crime; b) a apreensão de substância entorpecente em poder do(a) autor(a) do fato e/ou de dinheiro em espécie (normalmente fracionado em notas miúdas, não possuindo o(a) denunciado(a) explicação convincente para a origem do numerário), bem de apetrechos relacionados ao tráfico (balança, anotações de contabilidade, armas de fogo e munições, etc.); c) a existência de denúncia anônima relatando que uma pessoa, com as mesmas características físicas e vestes do(a) réu(ré), estaria traficando drogas no local em que o(a) denunciado(a) estava praticando o tráfico de drogas; d) o fato de o(a) acusado(a) ter sido flagrado por policiais em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes; e) a circunstância de o(a) acusado(a) ser conhecido no meio policial como traficante de drogas, responder a inquérito, já ter sido ou estar sendo processado, e/ou possuir condenação pela prática do referido delito. Em tais casos, ainda que o(a) autor(a) do fato não tenha sido flagrado comercializando entorpecentes, esses indícios (prova indireta) permitem que o magistrado conclua, em processo indutivo, ser ele(ela) traficante de drogas.

3. A materialidade delitiva foi comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo auto exibição, apreensão constatação e entrega (fls. 12/13 e 15), pelo auto de avaliação, pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), pelos documentos fotográficos (fls. 14), pelo relatório da autoridade policial (fls. 97/98) pelo laudo pericial de entorpecentes (fls. 93/95) e pelas demais provas encartadas nos autos.

4. A autoria é incontroversa.

Com efeito, restou demonstrado que no dia 01 de abril de 2021, por volta de 16h59, na Rua Antônio Nicolau, n.º 126, Bairro Jardim Redenção, nesta cidade e comarca de Itápolis/SP, o denunciado JOÃO RICARDO OLIVEIRA DA SILVA foi surpreendido por policiais militares vendendo, 3,5 gramas de maconha, acondicionada em um saco plástico tipo “ziplock”, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Conforme narrado na denúncia, policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram o denunciado JOÃO RICARDO OLIVEIRA DA SILVA em local conhecido como ponto de venda de drogas, entregando a droga que vendia para o usuário Valtenir Nogueira, que, por sua vez, repassou ao réu dinheiro como pagamento pelo entorpecente que lhe foi entregue.

Os policiais realizaram a abordagem de ambos e, em revista pessoal, encontraram com o usuário Valtenir Nogueira uma porção de maconha, e com o denunciado JOÃO RICARDO a quantia de R\$ 10,00 (dez reais), sendo 5 (cinco) notas de R\$ 2,00 (dois reais), provenientes da venda do entorpecente a VALDENIR.

Indagado, VALTENIR informou aos policiais que tinha acabado de adquirir a droga do denunciado, entregando a este a quantia de R\$ 10,00 (dez reais), em 5 (cinco) notas de R\$ 2,00 (dois reais). Já o denunciado João Ricardo confessou ter acabado de vender a VALTENIR uma porção de maconha em troca dos R\$ 10,00 (dez reais).

Vejamos.

O acusado JOÃO RICARDO OLIVEIRA DA SILVA, ao ser interrogado na fase policial, sustentou que “comprou uma porção de maconha para fumar com VALTENIR NOGUEIRA. Já em relação ao dinheiro que carregava, afirma que é de origem lícita, oriunda de seu trabalho” (sic) (fls.06).

Na audiência de instrução e julgamento, o denunciado JOÃO RICARDO OLIVEIRA DA SILVA sustentou que é usuário de drogas e que no dia dos fatos estavam fumando.

Compartilhou parte da droga que possuía para o seu consumo com VALTENIR. VALTENIR lhe pagou pelo compartilhamento da droga, porém o interrogado não solicitou o dinheiro. Aceitou o dinheiro que lhe foi fornecido por VALTENIR, pois estava precisando.

As testemunhas PEDRO PAULO RODRIGUES e WILSON ROBERTO FURLAN, policiais militares, em solo policial, disseram que “estavam em patrulhamento de rotina, a bordo da viatura de prefixo I 13221, em companhia de seu colega de farda, quando adentraram a rua Antonio Nicolau Del Guercio, local conhecido por ser ponto de atividade de tráfico ilícito de entorpecentes, quando avistaram um indivíduo de camiseta vermelha entregando dinheiro para um outro, sendo que este outro entregou um objeto para aquele. Como os dois indivíduos estavam de cabeça baixa, negociando, não viram a presença da viatura policial. Os policiais suspeitaram que tal atividade certamente seria referente a compra e venda de entorpecentes, motivo pelo qual efetuaram a abordagem. Os ora depoentes, o indivíduo que entregou a nota, foi identificado como VALTENIR; enquanto o sujeito que recebeu a nota foi identificado como JOÃO RICARDO e em troca cedeu um objeto. Em busca pessoal, realizada pelo soldado FURLAN, o rapaz que entregou as notas em dinheiro, foi encontrada uma porção de substância assemelhada ao entorpecente popularmente conhecido como maconha. Indagado pelos Policiais, VALTENIR disse que tinha acabado de adquirir aquela droga do indivíduo a quem havia entregado o dinheiro, a saber R\$ 10,00 (dez reais) em 5 (cinco) notas de R\$ 2,00 (dois reais). Por sua vez, na busca pessoal realizada no rapaz que os Policiais avistaram recebendo dinheiro, nominado JOÃO RICARDO, foi localizada a quantia de R\$ 10,00 (dez reais), sendo 5 (cinco) notas de R\$ 2,00 (dois reais). Indagado acerca daquele dinheiro, JOÃO RICARDO confessou que acabara de vender uma porção de maconha em troca dos dez reais. Ante tais fatos, os Militares decidiram conduzir ambos a esta Delegacia para as providências de Polícia Judiciária pertinentes” (sic) (fls. 04 – grifo meu).

Ao serem inquiridas na audiência de instrução e julgamento, as testemunhas PEDRO PAULO RODRIGUES e WILSON ROBERTO FURLAN narraram que estavam em patrulhamento pela Rua Antônio Nicolau Del Guercio, local conhecido como ponto de tráfico de drogas, e se depararam com 2 (dois) indivíduos fazendo contato. O indivíduo de camisa vermelha, de nome VALTENIR, passou algo para o réu, aparentemente dinheiro. O

acusado, por sua vez, entregou algo para VALTENIR. Em busca pessoal, localizaram em poder de VALTENIR uma porção de maconha e em poder do réu 5 notas de R\$ 2,00, totalizando R\$ 10,00. Indagado, VALTENIR disse que havia adquirido uma porção de droga do réu por R\$ 10,00. O acusado confessou a venda das drogas pelo valor de R\$ 10,00. O réu já era conhecido nos meios policiais por tráfico de drogas.

A testemunha VALTENIR NOGUEIRA, ao ser ouvida na fase policial, relatou que “nesta data, foi abordado por policiais militares, em sua posse, foi localizado uma porção de maconha, entorpecente este que havia acabado de comprar; Que a pessoa da qual comprou o entorpecente também foi abordada pelos policiais, juntamente com o declarante; Que ao lhe ser apresentado a pessoa de JOÃO RICARDO OLIVEIRA DA SILVA, o declarante afirmou que é a pessoa que lhe vendeu o entorpecente; Que pagou pelo entorpecente a quantia de R\$10,00 (dez reais) em notas de R\$ 2,00 (dois reais)” (fl. 05).

Ressalte-se que os depoimentos de policiais civis e militares reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão de ilícitos penais.

Além disso, é fato notório e de conhecimento geral que, nos crimes (e atos infracionais) de tráfico de drogas, impera a lei do silêncio, haja vista que a(s) testemunha(s) do fato, sentindo-se amedrontada(s) e temendo por sua integridade física e/ou de seus amigos e familiares, optam por se calar, por fornecer pouco(s) detalhe(s) a respeito da empreitada criminosa ou, simplesmente, por mentir à autoridade policial e/ou ao(à) magistrado(a). Em tal contexto, a(s) denúncia(s) anônima(s) e o(s) depoimento(s) de policiais civis e militares possuem grande valor probatório.

5. Tendo em vista que inexistem causas excludentes de tipicidade, de ilicitude e de culpabilidade, de rigor a condenação do(a) acusado(a).

6. A defesa pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei de Tóxicos.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Nos termos do § 2º, do artigo 28, da Lei n.º 11.343/2006, “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei de Tóxicos não exige que o agente seja flagrado praticando atos de mercancia para que sua conduta seja enquadrada no tipo penal do artigo 33, caput. Isso porque o delito de tráfico de drogas é de ação múltipla ou conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos 18 (dezoito) verbos núcleos do tipo (“importar”, “exportar”, “remeter”, “preparar”, “produzir”, “fabricar”, “adquirir”, “vender”, “expor à venda”, “oferecer”, “ter em depósito”, “transportar”, “trazer consigo”, “guardar”, “prescrever”, “ministrar”, “entregar a consumo” ou “fornecer drogas”).

Conforme já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, “para alicerçar a pretendida condenação por tráfico não é necessária a prova do comércio de substância entorpecente. O denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos de caráter de mercancia. Como seria extremamente, para não se dizer praticamente impossível apurar em conjunto e em sua integralidade, todas as fases em que se desenvolve essa atividade criminosa, contenta-se a lei, no esforço de combater as toxicomanias, em admitir que qualquer delas configura, por si só, delito contra a saúde pública” (TJSP; Apelação Criminal 1500705-48.2018.8.26.0274; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 24/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019 -

grifo meu).

Ademais, a condição de usuário ou dependente de drogas não é incompatível com a figura do traficante, tampouco afasta per si a imputabilidade do agente. Nesse sentido: TJMS, HC 01733320620158110000, Relator: Desembargador Gilberto Giralddelli, DJ 04/02/2016; TJDF, APR 0015443-41.2008.807.0001, Relator: Desembargador Souza e Ávila, DJ 03/02/2010.

In casu, embora a quantidade de entorpecentes apreendida (3,5 gramas de maconha) não seja incompatível com o porte droga para uso próprio, o acusado foi flagrado pelos policiais que o abordaram vendendo o entorpecente para terceiro, a testemunha VALTENIR, que afirmou ter adquirido as drogas do denunciado.

Além disso, o réu foi flagrado pelos agentes públicos em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, sendo conhecido nos meios policiais como traficante.

7. A defesa também postula a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 33, § 3º, da Lei de Tóxicos.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Nos termos do § 3º, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006, tipifica a conduta de "Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem".

O tipo penal em questão exige a presença simultânea dos seguintes requisitos: a) agir em caráter eventual, isto é, sem continuidade ou frequência; b) atuar sem objetivo de lucro, ou seja, o agente não objetiva obter qualquer tipo de vantagem ou benefício; c) atingir pessoa do relacionamento do agente (alguém conhecido antes da oferta da droga); d) ter a finalidade e consumir a droga em conjunto.

Em suma, nas lições de Guilherme Nucci, o delito em questão é perpetrado por aquele "que fornece substância entorpecente a um amigo, em qualquer lugar onde pretendam utilizar a droga em conjunto. Fazendo-o em caráter eventual e sem fim de lucro aplica-se a figura privilegiada" (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. 1. 10. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 390).

No caso dos autos, a versão do acusado de que as drogas apreendidas destinavam-se ao seu consumo e ao de seu colega não foram demonstradas, ficando isoladas do restante do caderno probatório. O próprio adquirente dos entorpecentes afirmou ter comprado a droga do acusado, sendo pouco crível a versão apresentada pelo denunciado na audiência de instrução e julgamento de que ao compartilhar o entorpecente, o outro usuário teria feito questão de lhe pagar pelo compartilhamento da droga. Deve-se ainda destacar que o tipo penal previsto no caput do artigo 33 da Lei de Drogas é de ação múltipla ou conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos 18 (dezoito) verbos núcleos do tipo ("importar", "exportar", "remeter", "preparar", "produzir", "fabricar", "adquirir", "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "prescrever", "ministrar", "entregar a consumo" ou "fornecer drogas").

Conforme já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, "para alicerçar a pretendida condenação por tráfico não é necessária a prova do comércio de substância entorpecente. O denominado tráfico ilícito de entorpecente é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas umas com as outras, desde a produção até sua entrega ao consumo, com atos de comércio propriamente ditos, bem como os que lhe são preparatórios, acessórios ou complementares e alguns até despidos de caráter de mercancia. Como seria extremamente, para não se dizer praticamente impossível apurar em conjunto e em sua integralidade, todas as fases em que se desenvolve essa atividade criminosa, contenta-se a lei, no esforço de combater as toxicomanias, em admitir que qualquer delas configura, por si só, delito contra a saúde pública" (TJSP; Apelação Criminal 1500705-48.2018.8.26.0274; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 24/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019 - grifo meu).

Ademais, a condição de usuário ou dependente de drogas não é incompatível com a figura do traficante, tampouco afasta per si a imputabilidade do agente. Nesse sentido: TJMS, HC 01733320620158110000, Relator: Desembargador Gilberto Giralddelli,

DJ 04/02/2016; TJDF, APR 0015443-41.2008.807.0001, Relator: Desembargador Souza e Ávila, DJ 03/02/2010.

7. É inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06. Para a aplicação do referido dispositivo legal é necessário que o Réu (i) seja primário, (ii) tenha bons antecedentes, (iii) não se dedique a atividades criminosas e (iv) não integre organização criminosa.

In casu, verifico que o acusado é reincidente (processo n.º 0003776-40.2015.8.26.0274).

Ademais, de acordo com os policiais militares, o acusado já é conhecido nos meios policiais por envolvimento com tráfico de entorpecentes, tendo sido abordado por milicianos em ponto de venda de entorpecentes.

II.3 - Da dosimetria das penas

1. Circunstâncias judiciais

Atentando para as diretrizes postas no caput do artigo 59 do Código Penal, caberá ao juiz, mediante fundamentação adequada e específica, e atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar a reprimenda em patamar que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Considerando-se que não há critério apriorístico fixado na legislação, o STJ e o TJSP têm utilizado como regra a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, vez que este é o quantum mínimo legalmente previsto para as causas de aumento de pena (majorantes). Contudo, a depender do caso concreto, poderá o magistrado utilizar exasperação superior à referida fração para cada circunstância, desde que indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, podendo, até mesmo, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea.

Nesse sentido, são os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 1168233/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018; AgRg no RESp 1632832/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 22/11/2018; HC 473.777/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018. Na mesma linha, são os seguintes precedentes do TJSP: Apelação 0066091-

63.2016.8.26.0050; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 25/10/2017; Apelação 0005712-

12.2017.8.26.0604; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2018.

No caso dos autos, nenhuma das 8 (oito) circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima) pode ser valorada negativamente.

Isto posto, estabeleço a pena-base no mínimo legal, qual seja, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

2. Circunstâncias agravantes e atenuantes.

Havendo circunstância agravante ou atenuante a ser isoladamente aplicada, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado como regra a fração de 1/6 (um sexto) para o incremento e para a diminuição, ressalvada fundamentação concreta que justifique a utilização de patamar superior, e respeitados os limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada no preceito secundário. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 1329257/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018; RESp 1738852/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018; AgRg no RESp 1660563/SP, Rel.

Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017. Todavia, no caso de concurso de circunstâncias agravantes ou atenuantes, observada a escala de preponderância prevista no artigo 67 do CP (circunstâncias que resultam

dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência), aquela que estiver melhor graduada irá se sobressair (STJ, AgRg no HC 415.317/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 01/08/2018; Resp 1285055/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014).

Deixo de reconhecer a atenuante do artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal, por se tratar de confissão qualificada. Nesse sentido, é o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: HC 119671, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013. Esse é também o entendimento do TJSP: Apelação Criminal 9000001-11.2014.8.26.0301; Relator (a): José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jarinu - Vara Única; Data do Julgamento: 15/08/2019; Data de Registro: 21/08/2019.

Reconheço a agravante da reincidência (processo n.º 0003776-40.2015.8.26.0274), razão pela qual aumento a pena-base em 1/6, e estabeleço a pena intermediária em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

3. Causas de aumento e de diminuição de pena.

Havendo concurso de majorantes e de minorantes, o artigo 68, § único, do Código Penal, estabelece as seguintes regras: a) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Geral, ambas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias; b) se existirem 2 (duas) ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, o juiz poderá aplicar todas elas (desde que obrigatórias) ou limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou diminua; c) se existirem, ao mesmo tempo, 2 (duas) causas de aumento, ou então 2 (duas) causas de diminuição, previstas uma na Parte Geral e outra na Parte Especial ou legislação especial, todas elas serão aplicáveis.

De acordo com a doutrina, se existirem simultaneamente causa(s) de aumento e de diminuição de pena, todas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias. "Em primeiro lugar, o magistrado aplica as causas de aumento, e depois as de diminuição. Não pode a sentença fazê-las recair ao mesmo tempo, compensando-as" (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo; Método, 2018, p. 398 - grifo meu).

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

4. Fixação do valor do dia-multa.

A ausência de informações acerca da situação econômica do réu, recomenda a fixação do valor unitário do dia-multa no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

5. Regime de cumprimento de pena.

Estabeleço o regime inicial de cumprimento de pena fechado, com fundamento no artigo 33, § 3º, e 59, caput, ambos do Código Penal. Embora a quantidade de pena aplicada autorize, em tese, a fixação do regime semiaberto, a reincidência indica(m) que o estabelecimento de regime carcerário mais gravoso é medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito que está sendo imputado ao agente.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2º, do CPP. Isso porque a inovação promovida pelo legislador, ao atribuir ao juiz do processo de conhecimento a responsabilidade pela progressão de regime (apesar de a redação do dispositivo legal sugerir tratar-se de detração penal), desconsidera que o instituto, próprio da execução criminal, não depende apenas do preenchimento do requisito objetivo, mas também do mérito do sentenciado, aferível através de boletim informativo, ou até mesmo de exame criminológico, a ser determinado pelo juiz da execução penal.

6. Substituição por penas restritivas de direitos.

Considerando-se a quantidade de pena aplicada, bem como a reincidência do agente, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,

pois, no caso concreto, a aplicação de penas alternativas revelar-se-ia inadequada para fins de reprovação e prevenção (geral e especial) do delito praticado pelo acusado.

7. Suspensão condicional da pena.

Deixo de proceder à suspensão condicional da pena, porquanto o acusado já foi contemplado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ademais, prevalece no STF e no STJ o entendimento de que o sursis é inaplicável aos crimes hediondos ou equiparados, pois a dimensão do benefício não se coaduna com a natureza do delito, em relação ao qual a própria CF, em seu artigo 5º, XLIII, determinou tratamento mais severo (STF, HC 101.919/MG; STJ, HC 197.268,SP).

III - DISPOSITIVO

1. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar o(a) acusado(a) JOÃO RICARDO OLIVEIRA DA SILVA como incurso(a) nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2. Concedo ao(à) réu(ré) o direito de recorrer em liberdade. Com efeito, não aportaram aos autos notícias de que o acusado tenha voltado a delinquir após os fatos objeto da presente ação penal. Ademais, não se acham presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

3. Outras disposições

Condeno o(a) acusado(a) ao pagamento das custas e despesas apuradas ao final. Deixo de estabelecer valor mínimo para reparação civil, tendo em vista inexistir prejuízo material constatado.

Transitada em julgado a sentença:

Inclua-se o nome do(a) condenado(a) no rol dos culpados.

Notifique-se o(a) condenado(a) para pagamento da multa no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 50 do CP;

Expeça-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 105 da Lei 7210/84;

Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD);

Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para fins do disposto no artigo 15, inciso III, da CF/88;

Porque não interessa a preservação das drogas apreendidas, oficie-se, determinando a incineração delas, mediante termo circunstanciado.

Demonstrado que o dinheiro apreendido era proveniente do tráfico de drogas, decreto seu perdimento em favor da União Federal, nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei 11.343/2006.

Procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Itapolis, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA